

1501500-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... autoria em relação ao crime de tráfico de drogas também é certa. Os elementos dos autos são hábeis a comprovar que o acusado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o acusado, imbuído do firme propósito de realizar o tráfico de entorpecentes, dirigiu-se para o local dos fatos, onde se encontra um condomínio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1501500-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501500-90.2021.8.26.0228 - 2021/000110

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE REHEM SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

ALEXANDRE REHEM SANTANA foi denunciado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c art. 61, II, j, do Código Penal, porque aos 16.01.2021, em ocasião de calamidade pública, por volta das 10h30, na R. Itamonte, nº 100, B. Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo e expunha a venda, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 357 porções, contendo 1.330,1g de Tetraidrocanabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", 271 porções, contendo 132,8g de Cocaína, 136 porções, contendo 34,3g de Cocaína, na forma de "crack", e 23 comprimidos, contendo 7,8g de Ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 37,10 em espécie.

Recebida a denúncia aos 27.01.21 (pp. 102/103).

O réu, preso, foi citado pessoalmente (p.158) e apresentou defesa prévia (pp. 121/132).

Ante a ausência de elementos a ensejar a absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (p. 142).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (pp. 159/160).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Indagadas as partes na fase do artigo 402 do CPP, pela defesa foi requerido a vinda do relatório policial por ocasião da abordagem pelo que foi deferido.

Após, foi dado vista as partes para apresentação de memoriais finais por escrito.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da agravante da calamidade pública, a imposição de regime aberto a ser substituído por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 1), boletim de ocorrência registrado sob o nº 328/2021 (pp. 2/4), auto de exibição e apreensão (pp. 10/11), laudo de constatação preliminar (pp. 19/22) e laudo de exame químico-toxicológico (pp. 169/171), bem como pela prova colhida em juízo.

A autoria em relação ao crime de tráfico de drogas também é certa. Os elementos dos autos são hábeis a comprovar que o acusado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o acusado, imbuído do firme propósito de realizar o tráfico de entorpecentes, dirigiu-se para o local dos fatos, onde se encontra um condomínio residencial, carregando consigo uma sacola, cujo em seu interior estavam localizados os entorpecentes, em suas roupas íntimas.

Todavia, naquele momento, Policiais Militares se encontravam no local, visando a operação ao combate do tráfico de drogas na região. Neste sentido, junto da equipe policial, encontrava-se também a cadela PBM DARA, a qual indicou odor de drogas vindo do réu, o qual se encontrava próximo dali.

Após observar os policiais, o acusado tentou empreender fuga, porém sem sucesso. Em revista pessoal, com ele foi encontrado uma sacola em suas roupas íntimas, bem como uma quantia de dinheiro em seu bolso de trás. Logo em seguida, a cadela PBM DARA encontrou, ainda, o restante das substâncias entorpecentes, a cerca de três metros do local onde o réu fora abordado.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o réu Alexandre Rehem Santana, negou os fatos que lhe são atribuídos, declarando que havia acabado de comprar maconha no local já que é usuário de drogas (p. 9).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, manteve a negativa

outrora apresentada, afirmando que estava no local para comprar droga, ocasião em que a polícia se aproximou, vindo a ser abordado juntamente com outros indivíduos. Disse não ter sido encontrada qualquer entorpecente em seu poder, pois ainda não havia comprado drogas. Levado para averiguação, somente na delegacia soube que estava sendo acusado do delito de tráfico de drogas.

A fala do réu, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou o delito que lhe é imputado.

A testemunha Rafael Paciencia Marques, policial militar e presente na diligência que prendeu o réu em flagrante, declarou que efetuavam Operação de Combate ao Tráfico de Drogas pelo local dos fatos, quando se depararam com o réu e outros indivíduos que, ao ver a viatura empreenderam fuga. Feita a abordagem no réu, foi encontrado uma sacola em suas vestes contendo entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro no seu bolso de trás. A cadela PBM DARA encontrou próximo do réu as demais drogas. Relatou que na ocasião o réu admitiu a traficância, bem como a propriedade das drogas encontradas pela cadela. Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi a declaração apresentada pela testemunha João Vitor Ferreira Benedito, também policial militar e presente na diligência, o qual acrescentou ter sido o responsável pela abordagem do réu. Disse que no dia dos fatos, além do réu, outras pessoas também foram abordadas, tratando-se de local conhecido pelo tráfico. Assim, nesses locais, a operação tem que ser rápida, pois costuma aglomerar diversas populares, atrapalhando a ação policial. Relatou que a cadela acabou por encontrar os demais entorpecentes, os quais estavam próximo ao réu, que na ocasião, admitiu a propriedade das drogas. Por declarou nunca ter visto o réu anteriormente.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O conjunto probatório carreado aos autos, mostra-se suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, visto que restou incontroverso que o réu trazia consigo, para entrega e consumo alheio, diversas substâncias entorpecentes denominadas popularmente como maconha, cocaína, crack e ecstasy.

Note que os depoimentos dos policiais demonstraram de modo firme e convincente o flagrante ocorrido, descrevendo a conduta do réu, em atitude suspeita, tendo ainda a cadela Dara encontrado as demais drogas próximo do local em que o réu foi abordado, ocasião em que admitiu informalmente aos policiais a propriedade das mesmas.

As circunstâncias que antecederam e concorreram à prisão em flagrante do acusado, a natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas (357 porções, contendo 1.330,1g de Tetraidrocanabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", 271 porções, contendo 132,8g de Cocaína, 136 porções, contendo 34,3g de Cocaína, na forma de "crack", e 23 comprimidos, contendo 7,8g de Ecstasy), bem como a forma como estavam acondicionadas, além do dinheiro trocado, indicam que o

réu as trazia consigo com o único fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, circunstâncias e local da apreensão.

Ademais, não é crível afirmar-se que os policiais apreenderam substancial quantidade de entorpecente para incriminar inocente, que sequer o conhecia até a data dos fatos, como admitido pelo próprio réu, em seu interrogatório.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de servidores policiais. Presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação ao réu, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

Insta salientar que a abordagem policial decorre do exercício do Estado do poder de polícia, que tem o dever de prevenir delitos e condutas que representem ofensa à ordem pública.

O fato é que trazer consigo e expor a venda entorpecente é fato típico penal e o acusado foi surpreendido com as drogas em seu poder, seja em uma sacola que portava nas partes íntimas, seja escondidas em um local próximo localizado pela cadela Dara. A ação policial, portanto, resultou na apreensão das drogas e prisão em flagrante do acusado. Assim sendo, diante desse cenário não há que se falar em ausência de justificativa para a abordagem do acusado.

Além disso, descabida a alegação de que estava no local apenas para comprar drogas para consumo próprio, posto que, ao avistar os policiais, o réu tratou de fugir. Caso estivesse no local apenas como usuário de drogas, não teria agido dessa forma.

Ademais, há contradição nas versões apresentadas, eis que na fase inquisitorial o réu falou que já havia comprado droga, enquanto que em Juízo, disse que ainda não havia adquirido o entorpecente.

A versão exculpatória do réu, portanto, mostra-se falsa quando confrontada aos depoimentos policiais, que narram, de forma uníssona, que o acusado foi encontrado com os entorpecentes dentro de uma sacola, bem como escondidas em um local próximo, os quais, certamente, eram destinados à comercialização.

Com efeito, o ônus de provar situação diversa da citada é do réu, como ensina Damásio de Jesus:

Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria. No tocante ao fato concreto cometido pelo sujeito, incumbe à acusação a prova dos elementos do tipo, sejam objetivos, normativos ou subjetivos. Em relação aos delitos materiais, a prova acusatória deve estender-se à demonstração da realização da conduta, da produção do resultado e do nexo de causalidade entre uma e outro. A prova do dolo e da culpa, elementos do tipo, incumbe também à acusação (contra, no sentido de que em decorrência da demonstração do dolo e da autoria o dolo é presumido: TJRJ, ACrim 1.316, RT 649/302). Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396- A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.

Por outro lado, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (CP, art. 61, II, j), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Na mesma toada, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021)

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta do réu subsome-se, in totum, ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Além disso, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes (pp. 100/101).

Para evitar bis in idem, deixo de considerar a natureza e a quantidade das drogas para fixação da pena base, pois este critério será utilizado quando da apreciação da figura privilegiada, na terceira etapa da dosimetria. Neste sentido:

Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (AgRg no REsp 1918495/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Por tais razões, fixo a pena base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), visto que o réu, nascido em 30/07/2001, era, na data dos fatos (16/01/2021), pessoa menor de 21 anos. Entretanto, deixo de considerá-la, tendo em vista ser defeso descer-se a quem dos limites previstos no tipo penal nesta etapa de dosimetria (STJ, Súmula 231), razão, pela qual, mantenho a pena-base fixada.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas na terceira fase de aplicação da pena.

Não é o caso de aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas (357 porções, contendo 1.330,1g de Tetraidrocanabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", 271 porções, contendo 132,8g de Cocaína, 136 porções, contendo 34,3g de Cocaína, na forma de "crack", e 23 comprimidos, contendo 7,8g de Ecstasy), a indicar o desvalor da conduta do réu, fato que pode e deve aqui ser considerado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Embora a quantidade de droga, por si só, não deva afastar a incidência do tráfico privilegiado, é necessário olhar atentamente ao caso concreto. O acusado foi detido com uma variedade e quantidade considerável de drogas, circunstâncias que indicam, de forma concreta, que ele está envolvido com atividades criminosas e que o crime apurado representa tráfico em larga escala, certamente ligado a organizações criminosas. A benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, deve prestigiar quem efetivamente mereça a redução da pena.

Além disso, a cocaína e o crack indicam maior lesividade e perigo social decorrente da conduta do réu. Não se pode dar ao acusado o mesmo tratamento que se daria àquele que comercializa pequena quantidade de maconha. Não se pode ignorar o efeito devastador da referida droga, em muito superior ao efeito de outras.

Assim, levando em consideração tais elementos, nego o benefício de redução da pena. Torno, portanto, definitiva a pena fixada alhures.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, ante ao quantum de pena aplicada, e a teor do art. 2º da lei federal 8.072/90, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo. A imposição de regime mais brando mostra-se incompatível com a gravidade do crime praticado.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, para o delito, no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Dos danos materiais/morais:

Quanto aos pretensos danos materiais e morais pretendidos na denúncia, a par da indicação do valor da pretensão (dois salários-mínimos), não se justificou como se chegou a tal valor, sendo que a operação matemática efetuada para contabilizar a média de gasto auferido com interações provocadas pelo uso de substâncias ilícitas não é parâmetro para se estabelecer um norte ao quantum da indenização. A indenização, por definição legal, pressupõe prejuízo certo e não meramente potencial. A pretensão, quanto ao tema, mas se aproxima com doação aleatória, o que é descabido na hipótese.

Nesse sentido ensina Guilherme de Souza Nucci:

Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (grifo meu)

No caso presente, em que pese o conhecimento notório dos malefícios que o uso de drogas ilícitas causa ao ser humano e, conseqüentemente, à coletividade, não há como mensurar o dano concreto, somente podendo se falar no dano potencial.

Daí porque, não há que se falar em condenação, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar ALEXANDRE REHEM SANTANA, RG: 50656057/SP, filho de Florisvaldo Bispo de Santana e Paula Adriana Santana Pereira Rehen, nascido aos 30.07.2001, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e a solver 500 (quinhentos) dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao réu pleitear o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas, bem como eventual contraprova, se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Declaro a perda dos demais objetos apreendidos com o réu (celular - p. 10/11), porquanto relacionados à traficância. Autorizo a destruição ou alienação.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 01 de abril de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA